

1503502-05.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Carolina estaria sendo usada para o tráfico e armazenamento de grande quantidade de entorpecente. Dirigiu-se ao local, onde avistou o réu com uma mochila, na qual havia dois tijolos de maconha e um caderno contendo anotações indicativas de tráfico. Questionado acerca do entorpecente, o acusado nada respondeu, disse que morava naquele local e franqueou a entrada da equipe no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503502-05.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2271038/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20648015 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5629/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2271038 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS PAULO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

MARCOS PAULO DA SILVA está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP.

Notificado (fls. 94), o réu apresentou defesa (fls. 151/154).

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022 (fls. 155/156) e o réu foi citado (fls. 191).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 196).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 196).

A defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, teceu considerações acerca da dosimetria da pena. (fls. 196).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3 e 4/5), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), fotografias (fls. 24/26 e 32/39), laudos periciais (fls. 63/67, 106/142 e 143/146), além da prova oral colhida na fase instrutória.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e a propriedade da droga apreendida, argumentando, em suma, que está sendo falsamente incriminado. Disse que, logo após chegar da casa de sua cunhada, onde tinha jantado, os policiais invadiram o imóvel e nada encontraram. Em seguida, eles trouxeram a mochila contendo a droga apreendida. Negou conhecer os policiais envolvidos na ocorrência e disse que é usuário de crack.

O policial militar Rodrigo relatou que estava em patrulhamento, quando recebeu denúncia de que uma residência na Rua Santa Carolina estaria sendo usada para o tráfico e armazenamento de grande quantidade de entorpecente. Dirigiu-se ao local, onde avistou o réu com uma mochila, na qual havia dois tijolos de maconha e um caderno contendo anotações indicativas de tráfico. Questionado acerca do entorpecente, o acusado nada respondeu, disse que morava naquele local e franqueou a entrada da equipe no imóvel, onde nada de ilícito foi encontrado. Ele apontou uma construção abandonada dentro de seu quintal, onde foi localizado o restante da maconha apreendida, a qual estava embalada de forma idêntica à droga que ele portava. Não conhecia o réu anteriormente e não havia mais ninguém no local.

O policial militar Hender confirmou, em linhas gerais, o depoimento de seu colega.

A ex-cunhada do réu, Maria das Graças, narrou que, na data dos fatos, o réu havia jantado em sua casa e, no outro dia, soube que ele havia sido preso. Sabe que ele usava drogas, todavia não tinha conhecimento de que praticasse a mercancia ilícita. Negou que houvesse trânsito de pessoas no fundo da residência do acusado ou que tivesse muro no terreno.

Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao réu.

Cumpre, desde logo, observar que inexistente vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão de delitos.

Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate à criminalidade. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

E, por óbvio, não foram as referidas denúncias que acarretaram a prisão do réu, mas o encontro da vultosa quantia de drogas, a corroborar as informações recebidas pelos policiais.

Ainda neste norte, nada foi alegado que seja capaz de afastar a credibilidade dos relatos apresentados pelos policiais militares ouvidos em juízo, que, no mais, revelaram-se coerentes e harmônicos com o restante da prova, até porque o acusado mencionou que sequer os conhecia.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

O réu portava 2 tijolos de maconha e indicou onde estaria mais 12 tijolos da mesma droga (idênticos ao que ele trazia consigo), quantia incompatível com o uso próprio.

E não enfraquece o conjunto probatório o fato do laudo pericial de fls. 143/146 não ter apontado elementos aptos a concluir que as anotações existentes nos cadernos apreendidos tenham partido do punho do réu, até porque ele poderia estar guardando tal objeto (e as drogas) para terceiro.

Em adição, o fato do acusado não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal.

Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TÓXICOS – TRÁFICO – Consumo – Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" – Inexigibilidade – Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente – Suficiência"(....)" (TJSP – Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 – São José dos Campos – 6ª Câmara Criminal – Relator Marco Antonio – J. 17.05.2007 – v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS – Tráfico – Caracterização – Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto – Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)"(TJSP – Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 – Sorocaba – 5ª Câmara Criminal – Relator Pinheiro Franco – J. 20.09.2007 – v.u). Voto nº 9.739.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que

não trouxe elementos a infirmá-lo. E, nessa toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a grande quantidade de droga apreendida (fls. 13/14). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase, aponto a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, aumento a pena de 1/6 para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Por fim, a despeito das alegações ministeriais, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à mingua de segura comprovação de que o réu se dedicasse às atividades criminosas por tempo considerável ou integrasse organização criminosa.

Todavia, cumpre observar que referido preceito legal fixa os requisitos necessários à sua aplicação, mas não estabelece parâmetros para escolha do quantum de diminuição a ser extraído entre as frações de 1/6 e 2/3. A esse respeito, oportuna a citação do Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Fux, esposada em seu voto no Habeas Corpus nº 111.097-MG:

"Destarte, se se entender pela ocorrência de bis in idem em decorrência da consideração das circunstâncias atinentes à quantidade e à qualidade da droga na majoração da pena-base e na dosagem da minorante do § 4º da Lei de Drogas, o magistrado ficará sempre adstrito à aplicação da minorante na fração máxima, tornando letra morta o preceito legal que determina seja ela aplicada na forma escalonada, por isso, a conclusão há de ser pela ausência de sobreposição, notadamente porque a pena-base e a minorante têm finalidades distintas: a primeira encontra justificativa na sanção necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, e a segunda visa a contemplar, com o abrandamento da punição, não necessariamente com a fração máxima de 2/3, o agente primário e de bons antecedentes que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Nesse sentido: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INSTRUMENTO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTUM DE REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. MENOR FRAÇÃO. 1. O legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deixando de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e maior frações indicadas para a mitigação, disciplinando a doutrina e a jurisprudência que devem ser consideradas as circunstâncias previstas no art. 59 do e Supremo Tribunal Federal especialmente o disposto no art. 42 da Lei Antitóxicos. 2. Juízo de proporcionalidade que admite a aplicação do redutor no percentual mínimo de 1/6, de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do CP, dada a quantidade e a espécie de entorpecente encontrado em poder do acusado. 3. Não há bis in idem na consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para negar a redução a maior na terceira etapa da dosimetria, mas apenas a utilização de

um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO." (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.403.921-MG - 2011/0085663-6 - 6ª T - rel. Ministro Vasco Della Giustina, 23.08.2011, v.u.).

Portanto, considerando a quantidade de entorpecente apreendida, reduzo a pena de 1/2 para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 388 dias-multa.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a primariedade do réu (fls. 177/178), fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e considerando, ainda, os motivos esposados na primeira fase.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecípada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

"O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão"

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu MARCOS PAULO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 388 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu ao processo preso e não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente em virtude da necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos apreendidos com o acusado. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o

necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA